


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

TERMO AUDIÊNCIA

Processo nº **0063495-09.2016.8.26.0050**
 Réu **HARRISON DIEGO DOS SANTOS**
 Artigo da Denúncia: 33, caput da Lei 11.343/06

Aos 24/04/2017, às 16:30h, na sala de audiências da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Marcos Alexandre Coelho Zilli, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, PRESENTE a testemunha ISAAC DE MELO e o réu HARRISON DIEGO.

Presente o Promotor de Justiça, **Dr. Orion Pereira da Costa** e a Defensora Pública em exercício nesta vara, **Dra. Mônica de Melo**.

A seguir, foi ouvida a seguinte testemunha arrolada em comum: ISAAC DE MELO LUZ.

Assim sendo, após ser entrevistado por sua defensora, deu-se o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução foi dada a palavra às partes, para pedidos de diligências, por estas foi dito que nada havia para ser requerido.

Na sequência, foi dado início aos debates, dada a palavra ao Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: “MM Juiz, autoria e materialidade do delito restaram efetivamente comprovados. O laudo pericial de fls. 166/168 confirma a característica dos entorpecentes apreendidos. A prova oral não deixa qualquer dúvida sobre a autoria. Os policiais Alexandre e Isaac relatam que faziam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avisaram o réu e outra pessoa que vendo a viatura policial iniciaram fuga. Foram perseguidos, sendo preso apenas o réu. Em sua posse encontraram cerca de duzentas e noventa porções de cocaína e dez de maconha, além de uma pequena quantia de dinheiro, sendo ele preso em flagrante. Interrogado, o réu negou a prática do delito apresentando versão que não encontra amparo na prova produzida, revestida de pouca credibilidade ao afirmar que passava pelo local e foi preso. A versão dos policiais é uniforme e coerente, não havendo razão para que seja colocada em dúvida, pois não conheciam o acusado anteriormente, não havendo razão para imputar falsamente a acusação. Depõem em juízo dando conta do trabalho desenvolvido, e agem em nome do estado, presumindo-se deste modo, a lisura de seu trabalho, até prova em contrário. Prestam compromisso de dizer a verdade como qualquer outra testemunha. O conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado nos termos da denúncia, levando-se em conta na aplicação da pena a sua reincidência, conforme certidões de fls. 113 e 165, fixando-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.”

Dada a palavra à defensora do réu, pela mesma foi dito: “MM Juiz, a testemunha policial militar Alexandre relatou em seu depoimento que estava em patrulhamento na avenida água vermelha e próximo de uma viela avistaram 2 indivíduos com atitude suspeita. Eles correram em direção à um córrego e o outro se evadiu. Na revista pessoal foi localizada uma sacola que continha drogas. Reconhece o acusado. Invólucros de cocaína e maconha. Mas,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

não se recorda a quantidade. De cocaína a quantidade era expressiva. De maconha era menos. Não se recorda se tinha dinheiro. Não se recorda dele de outras abordagens. Eles estavam conversando normal porém ao avistarem à polícia mostraram nervosismo e correram quando viram a polícia. Disse que era usuário. No bolso da blusa estava a sacola, num bolso modelo canguru. Disse que era usuário e depois não disse mais nada. A testemunha policial militar Isaac em seu depoimento relatou que estava em patrulhamento pela avenida água vermelha. Lá é ponto de drogas. Viram 2 indivíduos numa viela. Correram em direção à um córrego e somente ele foi detido. Localizaram as drogas e 5 reais com ele. Tinha cocaína (250) e maconha (10). Não confirmaram o tráfico. Eles estavam próximos um do outro e os dois saíram correndo. As drogas estavam dentro do bolso numa sacola. O réu em seu interrogatório disse que já foi processado por tráfico e foi condenado e cumpriu a pena. Estava em liberdade desde 2014. Trabalha na feira livre. Não era ele. A viatura passou e tinha acabado de deixar sua namorada numa viela e estava conversando com uma menina que era sua namorada. Era 6 da manhã e estava voltando de uma balada. Vieram com essa droga não sabe de onde. Não estava com nada, moeda. Disseram que era só uma averiguação e no DP apresentaram essa droga dizendo que era deles. Já viu o Oliveira passando de rotina porque mora ali perto. **I - DA ABSOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS** Embora os policiais relatassem que o local fosse ponto de tráfico apenas detiveram o acusado. Segundo seus depoimentos presenciaram o acusado conversando normalmente com uma pessoa. Não presenciaram mercancia de drogas. O réu nega qualquer envolvimento com drogas e disse ter sido detido por ter passagem e para averiguação e apenas quando chegou ao DP foi mostrada as drogas e atribuída a ele. Disse que estava conversando com sua namorada que tinha acabado de deixar em casa. Dessa forma, não há prova suficiente para uma condenação por trafico. Em razão da insegurança jurídica deixada pela situação narrada, defende-se aqui a ideia de que, quando absolutamente isolado e contraditório, os depoimentos das agentes responsáveis pela ocorrência não podem suportar uma decisão condenatória, mormente quando a negativa do réu, como no caso, é firme e coerente. Do contrário, a exceção acaba por transforma-se em regra, permitindo que o aparelho repressor do Estado praticamente decida quem será processado e quem ao final será condenado. Com efeito, não se nega a nobreza da função ou a honestidade da instituição. Pelo contrário, sabe-se que são os grandes responsáveis pela segurança pública de um Estado. Contudo, o processo penal é regido por princípios constitucionais que protegem a liberdade humana e limitam o jus puniendi do Estado Democrático de Direito, o qual tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, qualquer ingerência na esfera pessoal deve estar amparada pela Constituição Federal. Pretende-se argumentar que, um sistema processual penal não pode conter falhas, obscuridades e/ou incertezas. O suporte condenatório deve ser CERTO. De fato, o testemunho dos policiais tem eficácia probatória, assim como a confissão do acusado ou, qualquer elemento que sirva para elucidar os fatos. Contudo, nenhuma prova é absoluta em si mesma e, portanto, suficiente para lastrear uma condenação, quando isolada. A atual sistemática de investigação, que despreza toda prova que não emane dos próprios agentes do estado, sob o pretexto de que ninguém se presta a colaborar com a polícia ou com a justiça (verdadeiro sofisma, pois esta não é uma faculdade e sim um dever do cidadão - o que garante ao policial o direito de exercer a autoridade que se fizer necessária para a colheita da prova) acaba por transferir aos policiais que efetuam a prisão poder imensurável na persecução penal. Se aceito como verdade absoluta o depoimento daqueles, qual a possibilidade de defesa do acusado? O processo penal, sob a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

ótica constitucional, não pode admitir que a verdade seja posta por uma das partes. In casu, a verdade é posta por aqueles que efetuam a prisão. Ora, por que não acolher a versão do réu em detrimento da versão dos policiais? Por mais honesto que seja, será que um policial iria desdizer o seu parceiro? Se o fizesse, em tese, alguém incorreria em falso testemunho e/ou, eventualmente, em crime de abuso de autoridade. Constata-se, assim, que a condenação baseada exclusivamente em tais depoimentos, fere frontalmente o princípio do contraditório em seu aspecto substantivo, também denominado na doutrina alemã de “PODER DE INFLUÊNCIA”. Diante das circunstâncias colocadas, qual o poder de influência do réu? Nenhum! Destarte, a interpretação atual de autorizar tais testemunhos, isoladamente, revela-se inconstitucional por afronta patente ao contraditório substancial. O professor Fredie Didier Jr., aborda com maestria a temática dos princípios processuais constitucionais, aplicados, com maior razão, ao processo penal: *“O processo é um instrumento de composição de conflito – pacificação social – que se realiza sob o manto do contraditório. O contraditório é inerente ao processo. Trata-se de princípio que pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência; comunicação; ciência) e possibilidade de influência na decisão. Aplica-se o princípio do contraditório, derivado que é do devido processo legal, nos âmbitos jurisdicional, administrativo e negocial. Democracia no processo recebe o nome de contraditório. Democracia é participação; e a participação no processo se opera pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como manifestação do exercício democrático de um poder. Quais são os elementos que compõe a garantia do contraditório? Esta garantia desdobra-se em duas facetas. A faceta básica, que eu reputo a formal, é a da participação; a garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo. Isso é o mínimo e é o que todo mundo entende como princípio do contraditório. De acordo com o pensamento clássico, o magistrado efetiva, plenamente, a garantia do contraditório simplesmente ao dar ensejo à ouvida da parte, ao deixar a parte falar. Mas não é só isso. Há o elemento substancial dessa garantia, há um aspecto, que eu reputo essencial, denominado, de acordo com a doutrina alemã, de 'poder de influência'. Não adianta permitir que a parte, simplesmente, participe do processo; que ela seja ouvida. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do magistrado. Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do Magistrado – e isso é poder de influência, poder de interferir na decisão do Magistrado, interferir com argumentos, interferir com idéias, com fatos novos, com argumentos jurídicos novos; se ela não puder fazer isso, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a ouvida, com a participação; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão. Como poderia o magistrado punir alguém, sem que lhe tenha dado a chance de manifestar-se sobre os fundamentos da punição, por exemplo, demonstrando que os fatos em que se baseia o magistrado ou não ocorreram ou não permitem a aplicação da sanção? Seria punir sem ouvir; seria condenar sem dar a chance de defesa. Não é possível a aplicação de qualquer punição processual, sem que se dê oportunidade ao 'possível punido' manifestar-se previamente, de modo a que possa, de alguma forma, influenciar no resultado da decisão”. (Curso de Direito Processual Civil, Edições Podivm, Páginas 42/43)* De se destacar que o sistemático desprezo da palavra do réu em favor do depoimento do agente isolado viola ainda o princípio in dubio pro reo, já que a contrariedade existente entre estas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

provas se resolve em condenação e não absolvição. Evidentemente, que não se pretende absolutizar a negativa de autoria do réu (pois isto consistiria no equívoco diametralmente oposto). O que é necessário é considerar o conteúdo de sua defesa, reputando-as como válidas e aptas a formar o convencimento judicial como qualquer outra prova. Com efeito, quando inverossímil ou contrariada por todo o restante do conjunto probatório (e não apenas pela palavra dos policiais que o prenderam) a versão do réu dever ser afastada, impondo-se a condenação. Em sentido oposto, quando a prova da acusação se resume exclusivamente a palavra dos agentes, não havendo razões para reputar como incrível ou inverossímil a defesa apresentada pelos réus e por suas testemunhas é o caso de absolvê-los por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Em recente decisão assim manifestou-se o Tribunal de Justiça de São Paulo, (Apelação nº 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Des. SYDNEI DE OLIVEIRA JR., 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado aos 03 de março de 2011), em caso também envolvendo suposta traficância, e tendo como únicas provas os depoimentos policiais, o qual pela importância se transcreve: *“(...) Afinal de contas, as versões apresentadas se chocam e entrechocam, sendo salutar socorrer-se do vetusto in dubio pro reo. Uma vez presente à dúvida, presume-se, sem pestanejar, a inocência do acusado. Afinal de contas, in dubio pro libertate ou libertas omnibus rebus favorabilior est - na dúvida, pela liberdade; ou, em todas as coisas, a liberdade é mais favorecida, já diziam os romanos (CAIO. De regulis iuris. Digesto, Livro 50, Título 17), cujas locuções latinas são precursoras do conhecido e atual in dubio pro reo (...)”*. *“(...) não se está sustentado a completa inaptidão do testemunho de policial, em sede de processo criminal. O que se defende é coisa bem outra. Os policiais militares investigadores do fato, como verdadeiros assistentes da parte autora, não têm, sozinhos, em face da própria condição de servirem como longa manus do Ministério Público, enquanto ditam as provas, a isenção suficiente para demarcarem, através de seus exclusivos depoimentos, um justo e razoável juízo de reprovação penal. Admitir-se entendimento outro é o mesmo que fazer ouvidos moucos ao som do retumbante princípio da proporcionalidade, desequilibrando, a não mais bastar, as atuações dos atores processuais, em manifesto e desmesurado prejuízo à ampla defesa do acusado, tornando-o sempre a parte vulnerável da ação penal, com mínimas chances, para não se dizer nenhuma, de se ver livre da imputação (...)”*. (Grifo nosso) *“(...) É certo que os policiais não estão impedidos de depor - e isso nem se discute -, mas, porque prenderam certo acusado, seus exclusivos depoimentos não se apresentam idôneos para um definitivo esclarecimento da verdade processual, ou para embasar, com a segurança desejada, um justo édito condenatório do preso. Não são, certamente, imparciais, ainda mais quando, como no caso, suas falas são desmentidas pelo incriminado (...)”*. (Grifo nosso) Conforme se observa, o acórdão supra aplica-se como uma luva ao caso em testilha. As versões dos milicianos são frontalmente contraditas pela do réu e não encontram eco em qualquer outra prova trazida aos autos. Assim, imperiosa a absolvição dos réus, acompanhando-se consolidado entendimento dos Tribunais:

“Uma sentença condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo dúvida, chegando as provas somente ao crível, a justa solução é a absolvição” (RT 453/414). *“Para um decreto condenatório, é indispensável a existência de provas seguras, precisas, não bastando suspeitas ou indícios, mesmo que sejam veementes”* (JUTACRIM 62/206). *“Sendo conflitante a prova e não podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

prudente a decisão que absolver o réu” (TACRIM-SP – AP- Rel. Cunha Camargo – JUTACRIM – 20/370). “Sendo impossível optar com segurança entre as versões da vítima e dos acusados, quando nenhuma delas vem alicerçada em alguns outros adminículos objetivo fornecido pelos autos, é impositivo que se decrete a absolvição dos réus” (TACRIM-SP- AP- Rel. Érix Ferreira – RJD 24/37). Face ao exposto requer seja julgado improcedente a ação penal a fim de absolver o réu com fulcro no art.386, VII do CPP, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, se outro for o entendimento de V. Exa. a defesa vem requerer: **II – DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E À GARANTIA DO NE BIS IN IDEM** Neste passo, quanto à incorporação do princípio da proporcionalidade no direito brasileiro, cabe lembrar, de início, que, segundo preleciona Paulo Bonavides, *verbis*: “No Brasil, a proporcionalidade pode não existir enquanto norma geral de direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A noção mesmo se infere de outros princípios que lhe são afins, entre os quais se avulta, em primeiro lugar, o princípio da igualdade, sobretudo em se atentando para a passagem da igualdade-identidade à igualdade-proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de Direito (...). O princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, direito positivo em nosso ordenamento constitucional” (Curso de Direito Constitucional – Ed. Malheiros, p. 395/6). A proporcionalidade estaria, incluída, portanto, na vedação de excessos, ínsita ao art. 37 da Constituição Federal e flui do espírito que anima em toda a sua extensão e profundidade o § 2º, do art. 5º, o qual abrange a parte não-escrita ou não expressa dos direitos e garantias da Constituição. Conclui, assim, Bonavides: “admitir a interpretação de que o legislador pode a seu livre alvedrio legislar sem limites, seria por abaixo todo o edifício jurídico e ignorar, por inteiro, a eficácia e a majestade dos princípios constitucionais. A Constituição estaria despedaçada pelo arbítrio do legislador” (op. cit., p. 396). Acrescenta Alberto Silva Franco, quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade no âmbito penal: “Num modelo de Estado (Social) e Democrático de Direito, sustentado por um princípio antropocêntrico, não teria sentido, nem cabimento, a cominação ou aplicação de pena flagrantemente desproporcionada à gravidade do fato. Pena desse teor representa ofensa à condição humana, atingindo-a de modo contundente, na sua dignidade de pessoa. O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se em consequência, uma inaceitável desproporção” (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, 6ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 36). Neste passo, a Lei nº 11.343/06, ao fixar como pena mínima para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, causa de diminuição de 1/6 a 2/3 para primários, acabou por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que integre organização criminosa), como é o caso dos autos, é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

patamar de 2/3, implicando sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela não aplicação da causa de diminuição, pena de 5 (cinco) anos de reclusão. O peso da reincidência é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 da pena, sendo 2/3 aplicados em função da reincidência. Esta desproporção é inconstitucional, ainda, porque aprecia, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência, implicaria a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (em face de seus antecedentes) e não em razão do que o agente faz. Como mostra Muñoz Conde, *verbis*: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Dessa maneira, tal dimensão de acréscimo da pena (a que corresponde à negativa de aplicação da causa de diminuição) ofende a proporcionalidade, na medida em que possibilita aplicação de pena a maior pelos fatos pretéritos do que por aquele a que está sendo imputado ao agente. Nem se diga, por fim, da impropriedade de afastar-se regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas, ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no § 1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). No mesmo sentido, o ensinamento de Paulo Bonavides: “A lesão ao princípio é indubitavelmente a mais grave das inconstitucionalidades porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem constitucional não há garantia para as liberdades cujo exercício somente se faz possível fora do reino do arbítrio e dos poderes absolutos”. (op. cit., p. 396). Ainda que assim não fosse, cabe frisar que a não aplicação do redutor, por força da agravante da reincidência, consubstanciaria autêntico *bis in idem*, já que esta circunstância legal já será reconhecida na segunda etapa de cálculo da reprimenda. Portanto, deve a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ser aplicada em favor do acusado. **III - DA PENA BASE** A pena deve ser fixada no mínimo em face de todas as circunstâncias e da quantidade de drogas encontrada em poder do acusado. **IV - DO REGIME ABERTO, DA APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS E DA DETRAÇÃO.** Prosseguindo requer-se a fixação do regime inicial aberto. Neste diapasão, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

(circunstâncias judiciais favoráveis), não se pode afastar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Também inafastável o direito do réu ter sua pena privativa de liberdade substituída por sanções restritivas de direitos. É que o óbice outrora existente na lei de droga foi suprimido pela resolução do Senado Federal, que cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal, afastou o óbice legal a substituição da pena privativa de liberdade por delito de tráfico por sanção restritiva de direitos. O afastamento da substituição da pena, mesmo em caso de tráficos praticados por indivíduos primários, com bons antecedentes e conduta social adequada, tem por consequência o povoamento de nossas prisões por pessoas sem passagem criminal anterior e sob as quais sequer pesa suspeita de envolvimento com facções criminosas. Por estes motivos, o Senado Federal, através da resolução nº 5 de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Conforme artigo 1º o Senado Federal resolveu: “*É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS*”. Neste diapasão, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis), não se pode afastar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Por fim, na sentença deve se observar o disposto no art. 387, §2º do CPP, inserindo-se o réu no regime prisional subsequente, caso se verifique o tempo de prisão provisória em regime equivalente a fechado é igual ou superior a dois quintos da pena cominada ou caso a pena restante possa ser cumprida em regime menos gravoso. Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública requerer ao colhimento dos pedidos acima expostos.”

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DELIBERAÇÃO / SENTENÇA:

VISTOS. O Ministério Público ingressou com a presente ação penal, imputando ao réu **HARRISON DIEGO DOS SANTOS**, devidamente qualificado, a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em razão da posse, para fins de tráfico, de 296 porções de cocaína, com peso de 61,7g e de 10 porções de maconha, com peso de 0,9g, fato este ocorrido no dia 28 de julho de 2016, às 06:40 horas, na Avenida Água Vermelha, 10, Vila Curuçã, nesta Capital. Em sede de Departamento de Inquéritos Policiais, foi a prisão em flagrante convertida em preventiva. Não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar da denúncia, foi determinado, o processamento da ação penal (fls. 126/128). O réu foi citado (fls. 137). Apresentou resposta escrita através de Defensor Público (fls. 145/147). A denúncia foi, formalmente, recebida (fls. 152/154). Em início de instrução, foi ouvida uma testemunha comum. Nesta data, foi ouvida uma testemunha comum e, ao final, foi o réu interrogado. Não tendo sido requeridas diligências, passou-se aos debates. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos exatos termos constantes na denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu batendo-se pela fragilidade das provas colhidas. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade; a fixação de regime menos gravoso. Eis, em síntese, o relatório. **Passo, em seguida, a fundamentar. 1. Das provas produzidas.** A persecução penal foi instaurada por força de auto de prisão em flagrante, lavrado pela autoridade policial responsável pelo 67º Distrito Policial, após a detenção do acusado, executada por policiais militares que encontraram em seu poder certa quantidade de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

drogas. Instruíram o auto de prisão em flagrante o auto de exibição e apreensão (fls. 11), bem com laudo de exame preliminar de constatação (fls. 14). Quando da primeira audiência, o policial Alexandre confirmou o depoimento prestado em sede policial. U seja, estava em patrulhamento em local já conhecido pelo tráfico de drogas. Em dado momento, avistou duas pessoas em uma viela. Estes ao notarem a aproximação dos policiais, fugiram. Mesmo assim conseguiu deter o acusado com quem encontrou expressiva quantidade de drogas as quais estavam embaladas em invólucros. Na presente audiência, o policial, Isaac confirmou o depoimento prestado em sede policial. Estava em patrulhamento quando avistou o réu em companhia de uma segunda pessoa em local já conhecido pela incidência do comércio de drogas. Estes ao notarem a aproximação dos policiais saíram correndo. Foram em perseguição e conseguiram detê-lo, encontrando em poder do réu certa quantidade de drogas, em um dos bolsos de sua calça, bem como de quantia em dinheiro. Quando do interrogatório, o réu negou envolvimento na prática delituosa. Passava pelo local pois voltava da casa de sua namorada. Quando estava na viela quando foi abordado por policiais. A droga lhe foi apresentada pelos policiais. Na sequência, foi detido e levado ao distrito policial quando então, foi acusado de tráfico de drogas. **2. Da valoração das provas.** A ação penal é procedente. A materialidade foi demonstrada. Com efeito, o auto de exibição e apreensão aponta para o encontro de invólucros plásticos contendo o que aparentava ser entorpecente. O exame preliminar confirmou as suspeitas iniciais reconhecendo elementos indicativos de que a substância seria cocaína. Este resultado foi confirmado ao final com a juntada de laudo de exame químico toxicológico. O vínculo do réu com a droga apreendida restou demonstrado. Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais, os quais se apresentam consistentes e harmônicos. Segundo ambos o réu foi avistado em uma viela em companhia de uma pessoa que, ao final, não foi identificada. Ao notar a aproximação dos policiais, saiu em fuga, revelando, dessa forma, o seu possível envolvimento em atitude criminosa. Tais suspeitas foram confirmadas com a apreensão de expressiva quantidade de invólucros em sua posse direta. Como exposto, não há contradições. Não há razões para que tal prova seja desqualificada e desconsiderada. Neste ponto vale lembrar não ter a legislação processual abraçado o sistema das provas legais segundo o qual cada prova registra um valor aprioristicamente determinado. A bem da verdade, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador valorar as provas com liberdade, mediante confronto entre ambas, destacando-se os pontos contraditórios e convergentes. No caso em apreço, como mencionado, os relatos prestados pelos policiais são coerentes, coerência que se manifesta desde os estágios iniciais da persecução. Por outro lado, o réu apresenta versão que não foi respaldada por qualquer prova produzida. Não há razões que façam crer terem os policiais forjado a situação em flagrante. Dessa forma, a prova oral produzida tornou certa a imputação dada pela denúncia. A definição jurídico-penal é igualmente correta a grande quantidade de porções afasta a possibilidade de uso pessoal. Some-se a tal circunstância o local em que a prisão se deu, vale dizer em ponto já conhecido pela incidência do comércio ilegal de drogas. O dinheiro apreendido, por certo, era produto de venda. Aliás, as porções, via de regra, são vendidas por aquele valor. A procedência é, destarte, medida imperiosa. **3. Passo, em seguida a individualizar a pena.** O réu registra uma condenação anterior, já transitada em julgado, a qual será objeto de apreciação na segunda fase da dosimetria. De qualquer modo, as circunstâncias que cercaram o presente caso conferem uma maior reprovabilidade à ação. De fato, dentre os entorpecentes apreendidos existiam 296 porções de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

cocaína, em forma de pó. É sabido o alto poder corrosivo de tal substância. A quantidade, dessa forma, era excessiva. Estas circunstâncias, sem dúvida, conferem maior reprovabilidade, razão pela qual a pena base é fixada acima do limite mínimo e com o acréscimo de 1/6, obtendo-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. O réu é reincidente por força da condenação proferida nos autos do processo nº 436/2012, da 30ª Vara Criminal (fls. 156). A pena é, dessa forma, aumentada em 1/6, obtendo-se a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa. A agravante da reincidência não pode servir de impedimento para aplicação da causa de diminuição prevista pelo parágrafo quarto do art. 33 da Lei de Tóxicos. Isso porque já serviu de critério avaliativo na segunda fase. Tanto é verdade que se não tivesse sido considerada a reincidência, haveria redução da pena por força da atenuante relativa à confissão espontânea. Assim, a consideração da reincidência, novamente, caracterizaria a violação ao bis in idem. Em realidade, a vedação da aplicação da causa de diminuição se dá por outros motivos. Recentemente, decidiu-se que a causa de diminuição afastaria a equiparação do tráfico aos crimes de natureza hedionda. Esta nova percepção sobre o tráfico privilegiado traduz uma política criminal que busca reconhecer a menor reprovabilidade do tráfico de drogas de pequena proporção. Definitivamente não é a hipótese dos autos, dada a expressiva quantidade de drogas e também dada a natureza de algumas substâncias. Trata-se, portanto, de criminalidade que exige maior reprovabilidade, adequada com o mandamento constitucional que equipara o tráfico aos crimes hediondos. Mantenho, dessa forma, a pena nos patamares inicialmente estabelecidos. No mais, tratando-se de imputação de comércio ilegal de drogas, a imposição de regime mais brando, mostra-se inadequada em razão da gravidade natural da conduta criminoso. Aliás, o tráfico de entorpecentes propicia o enriquecimento fácil às custas do consumo e, sobretudo, do vício de alguns. Registre-se, ademais, o tipo de entorpecente apreendido, o qual provoca intensa e rápida dependência. Assinalo, por fim, ser o réu reincidente. Por tais razões, e atento à finalidade retributiva e também preventiva da sanção penal, fixo o regime inicial fechado. Quanto ao valor do dia multa, ausentes informações sobre a condição financeira do réu, cada qual é estabelecido em seu menor valor monetário. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, pois, a gravidade e a reprovabilidade do comportamento são incompatíveis com o regime jurídico mais brando das penas alternativas, tanto é verdade que se reconheceu no caso a necessidade de imposição de regime inicial fechado. **4. Decido.** Nos termos do exposto, julgo **procedente** a presente ação penal, para **condenar, como de fato condeno**, o réu **HARRISON DIEGO DOS SANTOS**, portador de RG 42.621.509, filho de Marina dos Santos, **à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.** O réu foi agraciado no curso do processo com a liberdade provisória. Compareceu aos atos processuais quando intimado, não dando mostras de que pretende se furtar da aplicação da lei penal. Desnecessária, portanto, a decretação de sua custódia. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se. Comprovado o vínculo entre o numerário apreendido e o tráfico de drogas, declaro o seu perdimento em favor da União. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. P.R.I.C..

Tendo as partes tomado ciência da sentença proferida e recorrido desta o réu, recebo o recurso tempestivamente interposto. Processe-se.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM Juiz, consoante o disposto no art. 1.269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo via física entregue às partes ao final dos trabalhos. Os depoimentos prestados em audiência estão documentados em mídia audiovisual, que permanecerá arquivada em cartório. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo. Saem todos cientes do teor do presente termo. Eu, Ricardo Bastianon, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Marcos Alexandre Coelho Zilli

Promotor(a):

Dr. Orion Pereira da Costa

Defensor(a):

Dra. Mônica de Melo

Réu

HARRISON DIEGO DOS SANTOS

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**